

第 19 問

以下の事例における甲及び乙の罪責について、論じなさい。

- (1) Aの唯一の法定相続人である甲は、相続によりAの全財産を手に入れるため、Aを自動車で人気のない山中に連れて行って殺害する計画を立てた。甲はAを殺害するための包丁を用意して自動車でAの家に赴き、荷物を持って来たので家の中に運ぶのを手伝って欲しいと言ってAを呼び出した。そして、トランクの中を覗き込んだAの後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトランクに閉じ込め、約5キロメートル離れた山中に向かって出発した。約10分後、車が殺害予定現場に到着し、甲がトランクの蓋を開けたところ、Aは手拭いで口と鼻を覆われたことによって窒息し、既に死亡していた。なお、甲は、トランクに閉じ込めただけでAが死亡するとは思ってもいなかった。
- (2) 乙は、Bを殺そうと思い立ち、Bを人気のない場所に誘った上、麻縄で力いっぱいBの首を絞めた。Bが動かなくなったため、乙は同人が死亡したものと思い、犯行の発覚を防ぐ目的で、乗用車でBを20キロメートル離れた海岸砂上まで運んでいった。岸に着いた乙は、Bを車から出し砂上に放置し、車に乗り込み自宅に戻った。だが、実は、Bは、砂上に放置される時点ではなお生存しており、その1時間後に砂末吸引により窒息死した。

第1 小問(1)

1 いわゆる早すぎた構成要件の実現の問題である。この問題については、最決平16.3.22【百選 I 64】（以下「平成16年決定」という。）が参考になる（**論点** 早すぎた構成要件の実現 司H25,R2,旧H19-1）。

総合 101 頁 論証 40 頁

2 甲がAの後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトラックに閉じ込めた行為（以下「第1行為」という。）は、殺人既遂罪（199）の客観的構成要件を満たすことは明らかである。

なお、甲は、相続目的で殺害しているが、このような間接的な利益を目的とする場合には、原則として、2項強盗は否定される（東京高判平元.2.27参照）（**論点** 「財産上……の利益」（236II）の意義）。

総合 206 頁 論証 89 頁

問題は、甲が、その後に山中でAを殺害する予定であって（以下「第2行為」という。）、故意がないとも思われる点である。

平成16年決定は、第1行為の時点で、第2行為に至る一連の行為の着手（43本文）をしており、その旨の認識は存在しているのであれば、故意を阻却することはないというロジックで殺人罪の成立を認めた。

そこで、実行の着手の有無が問題となるところ、平成16年決定は、以下のように述べ、これを肯定している。

「実行犯3名の殺害計画は、クロロホルムを吸引させてAを失神させた上、その失神状態を利用して、Aを港まで運び自動車ごと海中に転落させて死させるというものであって、第1行為は第2行為を確実に容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。」

この平成16年決定は、「密接性」と「危険性」の両面から検討している。具体的には、準備的行為と構成要件該当行為との不可分性、時間的場所的接着性、準備的行為終了後障害となるような特段の事情の有無という事情を挙げる。なお、判例は実行の着手の有無を判断するに際し、行為者の計画をも考慮に入れてよいと解している（以上について、最判平30.3.22【百選 I 63】山口裁判官補足意見も参照。）。

本問でも、平成16年決定に沿って検討すれば、実行の着手を認めることができるだろう。

3 もっとも、甲が、事前に予見していた因果経過と実際の因果経過は異なるため、因果関係の錯誤も問題となるものの、通説は、故意は阻却しないと解している。

平成16年決定も、「実行犯3名は、クロロホルムを吸引させてAを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、たとえ、実行犯3名の認識と異なり、第2行為の前の時点でAが第1行為により死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはな」と述べ、故意が阻却されないと結論付けている。

第 2 小問(2)

- 1 小問(2)は、いわゆるヴェーバーの概括的故意（遅すぎた構成要件実現）の問題である。

まず、乙は殺意をもってBの首を絞めているから（絞首行為）、これが殺人罪（199）の実行行為に当たることは明らかである。もっとも、Bは砂を吸って窒息死しており、そこには、乙がBを砂上に放置するという行為（投棄行為）が介在しているから、因果関係の存否が問題となる。

行為に内包される危険が現実化したかという判例の判断枠組みを前提とすれば、第1行為と第2行為には一定の関連性があるので、第1行為の危険性が結果となって現実化したといえることができ、因果関係は認められるだろう。

- 2 次に、乙は、Bを絞殺しようと思っているが、現実にはBは砂を吸って死亡しているから、因果関係の錯誤が問題となる（**論点** 因果関係の錯誤  司R2,予H23,R1,JBH15-1）。

上記のように、通説は、因果関係の錯誤では故意を阻却しないと解している。判例にも、理論構成は必ずしも明らかではないものの、本問と同様の事案について殺人既遂罪の成立を認めたものがある（大判大12.4.30【百選I15】）。

- 3 以上から、乙には殺人既遂罪が成立する。なお、投棄行為を別途法的評価の対象にすれば過失致死罪（210）の構成要件に該当するだろうが、死の結果の二重評価を避けるため、殺人既遂罪に吸収されると解すべきだろう。

 総合 39 頁  論証 9 頁

第1 小問(1)について

1 強盗殺人罪（240後段）の成否

↓

2 項強盗罪の成否

↓

「財産上……の利益」に相続権が含まれるか

↓

否定説

↓

強盗殺人罪不成立

↓

2 殺人罪の成否

↓

第1行為から死の結果が発生することについての認識がなく、未必的な故意（38 I）すら問うことができない

↓

第1行為の時点で第2行為に至る客観的な危険性が発生したがゆえに第1行為から第2行為に至る一連の殺人の「実行」の「着手」（43本文）が認められ、その認識が認められるとして故意責任を問うことができないか

↓

「実行」の「着手」は密接性及び危険性の基準を持って判断する

その際には、①準備的行為と構成要件該当行為との不可分性（必要不可欠性）、②時間的場所的接着性、③準備的行為終了後障害となるような特段の事情の有無等を考慮する

↓

あてはめ

↓

「実行」の「着手」肯定

↓

3 因果関係の錯誤

↓

故意を阻却しない

↓

4 殺人既遂罪成立

第2 小問(2)について

1 殺人罪の実行行為性肯定

↓

2 因果関係の存否

↓

危険の現実化説

↓

あてはめ

↓

3 因果関係の錯誤

↓

故意阻却しない

↓

4 殺人既遂罪成立、過失致死罪（210）はこれに吸収される

第1 小問(1)について

1 甲は、相続によりAの全財産を手に入れるために、殺意をもってAを殺しているため、2項強盗殺人罪（236条2項、240条後段）が成立する可能性がある。同罪が成立するためには、前提として2項強盗罪が成立することが必要となる。相続によって得られる利益（相続の開始による財産の承継）は、「財産上……の利益」に当たるか。

この点について、「財産上……の利益」は1項強盗との均衡から、利益の取得が財物の占有移転と同視できるだけのものでなければならず、利益を取得したといえるためには、具体的・直接的な利益を現実取得したといえなければならない。

そのため、一般的にみて、取得において一定の手續が要求される相続によって得られる利益は具体性・直接性を欠き、「財産上……の利益」とは評価できない。

したがって、2項強盗は成立せず、強盗殺人罪も成立しない。

2 そこで、改めて、「人を殺した」ものとして殺人既遂罪（199条）が成立するか、検討する。

甲は、Aの後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトランクに閉じ込めたところ（以下「第1行為」という。）、Aはこれによって口と鼻を覆われたことが原因となって窒息し、死亡している。

したがって、殺人罪の客観的構成要件該当性は認められる。

もっとも、甲の計画では、第1行為の後に、山中で殺害する（以下

1

「第2行為」という。）予定であったため、甲には第1行為から死の結果が発生することについての認識がなく、未必的な故意（38条1項）すら問うことができない。では、第1行為の時点で第2行為に至る客観的な危険性が発生したがゆえに第1行為から第2行為に至る一連の殺人の「実行」の「着手」（43条本文）が認められ、その認識が認められるとして故意責任を問うことができないか。

「実行」の「着手」の有無は、43条の文言上の制約からくる構成要件該当行為への密接性、及び未遂犯の実質的処罰根拠から導き出される法益侵害ないし構成要件の実現に至る現実的危険性の二つの基準をもって判断すべきである。

そして、かかる密接性・危険性の判断は、行為者の計画も考慮に入れた上で、①準備的行為と構成要件該当行為との不可分性（必要不可欠性）、②時間的場所的接着性、③準備的行為終了後障害となるような特段の事情の有無等の諸事情を総合的に考慮して決すべきである。

甲の計画によれば、①第1行為は第2行為を確実かつ容易に行う上で必要不可欠な行為である。②また、第1行為を行った場所から第2行為を行う予定であった山中までの距離は約5キロメートルであって、車で約10分で到着することができたのであるから、時間的場所的接着性も認められる。さらに、人気のない山中まで自動車で移動して殺害する予定であったため、③第1行為後、第2行為に至るまでの間に障害となるような事情は特に見当たらない。

よって、第1行為は第2行為に密接な行為であり、第1行為を開始し

2

た時点で既に殺人に至る客観的な危険性が認められるから、その時点で、第 1 行為から第 2 行為に至る一連の殺人の「実行」の「着手」があったといえる。

3 そうだとすれば、甲にその旨の認識が認められるとして、故意が認められるようにも思われる。しかし、甲が予定した因果の流れとは別の経路によって結果が発生している。

では、このように因果関係に錯誤がある場合、故意は認められるか。

この点について、因果関係に錯誤があったとしても、行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが構成要件の範囲内で符合している限り、行為者は規範に直面し、反対動機を形成する機会を与えられていたといえ、行為者に故意責任を問うことができる。

本問では、甲が予定していた A 死亡という因果経過には、危険実現が認められるため、故意を阻却することはない。

4 以上から、甲には殺人既遂罪が成立する。

第 2 小問(2)について

1 乙が殺意をもって B の首を絞める行為（以下「絞首行為」という。）

は、B 死亡の直接的・現実的危険性を有する行為であり、殺人罪（19 9 条）の実行行為に該当する。

2(1) しかし、乙は B を砂上に放置（以下「投棄行為」という。）し、これにより、B は窒息死している。そこで、上記行為との間の因果関係が認められないのではないか。

(2) 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重

3

い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという法的評価の問題である。

そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。

(3) 確かに、B の死の結果は、B が砂を吸ったことによる窒息によって生じている。しかし、被害者の殺害を企図して行為に及んだ者が、犯行の発覚を防ぐため、殺害行為の直後にその者の死体を砂上に放置する行為に及ぶことも、決して偶発的な事態ではないから、投棄行為まで含めて、行為の危険性を判断すべきである。

したがって、絞首行為から投棄行為を経て結果が発生したことは、行為に内包された危険性が結果となって現実化したものと評価することができる。

3 もっとも、乙は頸部圧迫による B 死亡という因果経過を認識しているから、因果関係に錯誤がある。

そこで、この点が故意の成否に影響を与えるか、上記の基準をもって判断するに、乙は、頸部圧迫による B の死亡という、危険の現実化が肯定できる因果経過を認識している。

よって、故意を阻却しない。

4 以上から、乙には殺人既遂罪が成立する。なお、投棄行為を別途法的評価の対象にすれば過失致死罪（210 条）の構成要件に該当するだろうが、死の結果の二重評価を避けるため、殺人既遂罪に吸収されると解すべきである。

以上

4